

1500265-19.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL DE SOUZA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

CARLOS DANIEL DE SOUZA BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 14, caput e no artigo 16, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500265-19.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500265-19.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL DE SOUZA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

CARLOS DANIEL DE SOUZA BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 14, caput e no artigo 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 26 de janeiro de 2021, por volta das 10h30min., na Travessa Emília Faria França, 10, Pestana, nesta cidade e Comarca, guardava e ocultava, para

comercialização e consumo de terceiros, (i) 38g de substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (maconha), dividida e acondicionada em 22 (vinte e dois) invólucros plásticos, (ii) 19,6g de substância entorpecente denominada tenanfetamina (ecstasy), dividida e acondicionada em 48 (quarenta e oito) invólucros plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 13/16, laudo de constatação preliminar de fls. 23/26 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 243/245).

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas, nesta cidade de Osasco, CARLOS DANIEL DE SOUZA BARBOSA portou arma de fogo, munições e acessório, de uso permitido, consistentes em 01 (uma) pistola, da marca Taurus, calibre 380, 10 (dez) cartuchos íntegros do mesmo calibre e 01 (um) carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de fls. 206/212).

Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas, nesta cidade de Osasco, CARLOS DANIEL DE SOUZA BARBOSA possuía no interior de sua residência, munições, de uso restrito, consistentes em 01 (um) cartucho íntegro, calibre 357, 10 (dez) cartuchos íntegros, calibre 380, 1 (um) cartucho íntegro, calibre 22, 05 (cinco) cartuchos íntegros, calibre 32 e 02 (dois) cartuchos íntegros, calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de fls. 204/208).

Denúncia recebida em 01 de fevereiro de 2021 (fls. 95).

Réu citado (fls. 111). Resposta apresentada (fls. 114/119).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 234/239).

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, regime menos gravoso para início do cumprimento da pena, e devolução dos bens apreendidos (fls. 289/302).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal procede parcialmente.

Em juízo, os policiais relataram que receberam uma denúncia anônima de que no local dos fatos residia uma pessoa que praticava roubos de moto com a mochila do Ifood. Realizaram diversas campanhas no endereço indicado, até que identificaram o réu entrando no imóvel. Durante a abordagem, o acusado se evadiu para o quintal e pulou o muro em um terreno baldio, onde foi detido. Estavam em três viaturas.

Os policiais Rosa e Raucley disseram que presenciaram o momento que o acusado, durante a fuga, dispensou uma arma de fogo municada (pistola 380). Na residência encontraram drogas (maconha e ecstasy) e munições de diversos calibres na cômoda no quarto. Também localizaram supostos pertences de vítimas de roubos (capacetes, carteiras, anéis, correntes) e a mochila do Ifood.

O policial Washington estava na parte dos fundos da casa e deteve o acusado no momento em que ele pulou no terreno. Disse que o acusado tentou fugir, mas deitou no chão quando viu que estava cercado. Não presenciou a dispensa da arma, nem a busca na residência.

Interrogado, o acusado negou as práticas delitivas e apresentou versão própria para os fatos. Disse que morava no local e estava saindo, quando os policiais dispararam dois tiros no portão. Nega que tenha pulado o muro. Aduziu que sua tia mora no mesmo quintal e presenciou os fatos, e que dividia a residência com um amigo chamado João. Informou que os policiais ficaram uma hora e meia no interior da sua residência e que quebraram alguns móveis. Negou uso de ecstasy e disse que já usou maconha. Afirmou que trabalha com a venda de pratas.

Todavia, sua versão restou isolada nos autos. A Defesa não produziu provas que mitigassem os depoimentos colhidos ou corroborassem as alegações do réu, como por exemplo, arrolar a tia do acusado que teria presenciado os fatos ou o suposto amigo que com ele residia.

Embora os depoimentos de policiais, porque envolvidos com a ocorrência, não possam ser considerados como prova máxima ou de fé pública, não obstante a relevância da função que exercem, são, tais depoimentos, elemento de prova como qualquer outro. E reclamam harmonia com o conjunto probatório produzido durante a persecução penal. É o que ocorre nos autos. Não existem contradições nos relatos ou fato novo que possa mitigar a prova acusatória.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador” (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

Restou incontroverso que o acusado residia no local, e que foram encontradas as drogas e a arma de fogo descritas na denúncia.

A materialidade está demonstrada através do auto de exibição e apreensão (fls. 13/16), laudo de constatação preliminar (fls. 23/26) e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 181/183. Outrossim, o laudo da arma apreendida atesta sua potencialidade lesiva (fls. 209/212).

Não caracterizada a hipótese do art. 28 da Lei 11.343/06, em razão do teor dos relatos. Sem lastro também a alegação de insuficiência probatória.

Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama o desfecho condenatório com relação para a prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por outro lado, não procede a ação em relação ao crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03. De início, insta pontuar que, não obstante conste na peça acusatória que a munição calibre 357 seja de uso restrito, verifica-se que a Portaria nº 1.222/19 traz na listagem de seu “anexo A” que se trata, na verdade, de uso permitido.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, a acusação não procede quanto à apreensão das munições. Ora, se exigimos das armas portadas ilegalmente potencialidade lesiva, porque se inoperantes não caracterizam o ilícito penal, isto significa que o artefato apreendido deve ter, em si mesmo, uma possibilidade de dano, um risco inerente à segurança pública.

Não é a situação dos autos. A apreensão dos cartuchos descritos na denúncia não revela, circunstancialmente, um perigo real à sociedade. Sem o revólver, a munição para nada serve, já que tem caráter acessório ou funcional.

A proibição decorre da política criminal implementada pela Lei 10.826/03, que em última análise visou evitar o comércio ilícito e nocivo de munições. Mas, para tanto bastavam as sanções administrativas, como multas, restrições de direitos, apreensões e cassações de licenças, mas não pena de prisão, com - note-se - proibição de responder o processo em liberdade.

A tipificação da porte ilegal de munições fere diversos princípios constitucionais, dentre eles a proporcionalidade, a ofensividade, a fragmentariedade.

O primeiro, porque a sanção é a mesma prevista para o porte de arma de fogo municada, conduta que, de longe, é de maior gravidade. Portanto, ignorados os princípios correlatos da razoabilidade, adequação e necessidade.

E a conduta, em si mesma, não é ofensiva à coletividade, como já dito.

Segundo Luis Flávio Gomes, a ratio legis da criminalização das armas de fogo clandestinas é o efetivo perigo que representam para a segurança e tranqüilidade de vários bens jurídicos fundamentais (vida, integridade física, liberdade, patrimônio, etc.). Estes bens jurídicos não estão imediatamente tutelados pela lei específica, mas são a razão de ser da norma, porque o legislador acabou antecipando a barreira de proteção dos interesses individuais, elegendo um bem jurídico coletivo "com função representativa" para constituir o objeto primário da tutela.

Ou seja, cria-se um "bem jurídico referencial", antecipando-se a barreira protetiva para punir a situação de perigo, em razão da mera possibilidade de dano. Ocorre que o porte de projéteis não gera esta "situação de perigo".

Quanto à fragmentariedade, o Direito Penal não é, nunca foi e não pode ser visto como medida de segurança pública. Pela ciência penal não se resolve a violência urbana, não serão solucionados os problemas relativos à criminalidade. Para tanto, é necessário o concurso dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como efetiva participação da comunidade. Ocorre que no Brasil, como resposta emocional aos graves problemas sociais do país, lança-se mão das leis penais como primeira alternativa para, de forma utópica, se alcançar a paz social inexistente, embora a Justiça Criminal devesse ser a última instância de 'socorro'.

A tipificação penal não deveria alcançar toda e qualquer conduta. Insignificância penal, tipicidade material e adequação social são conceitos que não podem ser esquecidos.

Em atenção ao caráter fragmentário do Direito Penal, a intervenção mínima é premissa maior para a sua aplicação. De se lembrar, aqui, que o "direito penal mágico", a banalização do sistema penal, a roupagem política que hoje se confere às normas penais - influenciadas até pelas telenovelas!! - conferem utilização desvirtuada (para não dizer catastrófica) da ciência.

A proteção aos bens jurídicos amparados pela lei deve ser sempre subsidiária, resultado de uma progressiva tutela jurídica que se inicia em esferas extrapenais (cíveis, administrativas, comerciais), de maneira que o direito penal (o mais drástico instrumento disponível no ordenamento jurídico) somente possa ser invocado em última instância, para a proteção dos valores fundamentais da sociedade. A existência de um delito está vinculada a uma efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela lei. Para a "determinação do injusto", devemos, antes de mais nada, verificar se realmente ocorreu uma ofensa ao bem jurídico. A lesão ao bem jurídico (ou sua exposição concreta a perigo em determinados casos) é requisito necessário

para podermos considerar a própria existência de um crime.

Assim, de rigor a absolvição relativa ao delito previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

Passo à fixação da pena.

- Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

O réu não ostenta antecedentes criminais. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes atenuantes e agravantes.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, considerando a primariedade, diminuo a pena-base em 2/3 (dois terços).

A minguada de demais causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e da primariedade.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime fechado e o impedimento à progressão não atendem o princípio constitucional da individualização da pena, balizado justamente pelos méritos dos acusados. O critério é justo, porque leva em conta circunstâncias pessoais de cada condenado. Além disso, corrobora a teleologia ressocializadora da pena, porque estimula o bom comportamento carcerário, a higidez psicológica e não rompe as relações sócio-afetivas, tão necessárias para a reinserção do cumpridor de pena na sociedade.

Ora, basta breve experiência na Corregedoria Permanente de Presídios e Cadeia para se perceber, na prática, o desencontro da impossibilidade da progressão com todo o sistema de execução penal, tantas vezes criticado, mas espelho de equilíbrio entre direitos e deveres, que prescreve garantias e punições sem o "afã" dos tempos atuais. Preso sem progressão é preso sem estímulo; certamente voltará em piores condições para a sociedade. Preso com progressão é mais vezes avaliado, está sempre sendo testado na sua autodisciplina antes de ser definitivamente devolvido ao convívio social.

Além disso, o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art.5º, XXXV) foi por completo ignorado, ao se arrancar do Poder Judiciário a análise, o juízo sobre a progressão do condenado em determinados crimes. Retirado o poder-dever de individualização da pena no processo de execução, é manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts. 2º e 60, §4, inc. III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

E não se olvide que a proibição da progressão traz 'condições explosivas' para as administrações prisionais. Nas lições de Alberto Silva Franco, 'nada pior num estabelecimento penitenciário, do que um condenado sem nenhuma perspectiva de ser libertado ou, ao menos, receber regime penitenciário mais favorável, antes do término de uma pena privativa de liberdade, de longa duração' (Crimes Hediondos, 3ª ed. RT).

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante - a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e, não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas."

- Artigo 14 da Lei 10.826/03

O réu não ostenta antecedentes criminais. Com lastro no art. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base no mínimo legal.

Ausentes atenuantes e agravantes.

A minguada de demais causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como pena definitiva 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e da primariedade.

Concurso Material de Delitos

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, totalizando a reprimenda em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR CARLOS DANIEL DE SOUZA BARBOSA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 03 (TRÊS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime aberto, e ao pagamento de 176 (CENTO SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput da Lei 11.343/06, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

B) ABSOLVER CARLOS DANIEL DE SOUZA BARBOSA, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Recurso em liberdade.

Uma vez confirmada a presente decisão, determino a incineração da droga apreendida,

nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos, por ora indefiro o pedido. Como bem ponderado pelo Parquet, os documentos juntados aos autos não demonstram a propriedade ou a posse lícita dos objetos, já as notas apresentadas do celular não estão em nome do réu e as notas das joias foram emitidas em data posterior aos fatos. Outrossim, não foi acostado qualquer documento que comprove a propriedade da motocicleta.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Osasco, 19 de novembro de 2021.